

1515987-31.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... demasiadamente conhecido como ponto de tráfico, quando colocou um saco plástico no interior do boné que estava na cabeça e foi passar pelo "fluxo", demonstrando nervosismo. Tal conduta, somado ao local, deu guarida para que os guardas o abordassem, já que havia indícios de estado flagrancial. Portanto, perfeitamente legítima a abordagem in casu. Nesse sentido: "1. A primeira parte do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, 1º Pav., Rua 10, sala 329, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (11) 2868-7171, São Paulo-SP - E-mail: sp29cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:1515987-31.2022.8.26.0228 - 2022/000852Classe - AssuntoProcedimento Especial da Lei AntitóxicosRéu:CLEITON WEBER BALOC

Aos 26 de setembro de 2022, às 16:00 HORAS, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, na sala de audiências virtuais da 29ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, foi declarada aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento designada nestes autos. Apregoados, compareceram o (a) Digníssimo (a) Promotor (a) de Justiça, Dr. (a) Cinthia Gonçalves Pereira, o réu CLEITON WEBER BALOC e seu(sua) Defensor(a) Dra. Mariane Vinche Zampar Defensoria Pública /SP OAB /SP. Declarações e depoimento(s) colhido(s) pelo sistema audiovisual, gravados na plataforma Teams, com a concordância dos presentes. A qualificação dos presentes foi, nesta data, atualizada no sistema eletrônico e se encontra à disposição das partes, com as ressalvas do Provimento CG 32/2000, em se tratando de vítima ou testemunha protegida. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas Edson e Diego Guardas Cíveis Municipais, após o que o réu foi interrogado. AS PARTES NÃO SE OPUSERAM QUE A AUDIÊNCIA OCORRESSE PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Pela Defesa foi dito que: : MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, Cleiton Weber Baloc, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque nas condições de tempo e local descritas na inicial, guardava, vendia e ocultava, para consumo de terceiros, 141 porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de 26,2 gramas; conforme auto de exibição e apreensão a ser juntado e laudo de constatação de fls. 11-13, substância entorpecente que determina dependência física ou

psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia (fls. 75/76), foi apresentada defesa prévia (fls. 110/111). Em instrução, procedeu-se à inquirição das testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório do acusado. É o breve relatório. De acordo com o conjunto probatório coligido aos autos, a pretensão punitiva merece prosperar. A materialidade encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 13/15, bem como pelos laudos de fls. 17/19 e 103/105 confirmando a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. Quanto à autoria, idêntica certeza se afigura. Os guardas municipais Edson Marques da Costa e Diego de Espírito Santo (fls. 10/12) relataram que estavam no interior da viatura pelo local dos fatos, momento em que, pela Rua Mauá, avistaram o acusado, o qual demonstrou nervosismo ao avistá-los. Procederam à abordagem do réu, encontrando no interior de seu boné 141 porções de crack e o valor de R\$ 111,50 em dinheiro. O acusado admitiu a posse das drogas, sendo detido em flagrante. Nesta audiência, reiteraram o teor de seus depoimentos, acrescentando que a droga foi apreendida dentro de um saco plástico no interior do boné usado pelo réu, o qual disse “caiu a casa” admitindo a posse da droga. Não foram apreendidos instrumentos para uso de entorpecente com o acusado, o qual não aparentava ser morador de rua. Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu confessou a prática delitiva, fornecendo detalhes da comercialização dos entorpecentes no local (fls. 01/03 – peças sigilosas). Em Juízo, contudo, negou estar em poder das drogas apreendidas, sendo que é usuário de drogas na “cracolândia”. Porém, transportava drogas no local, sendo que o seu pagamento era feito em pedras de crack. O conjunto probatório coligido aos autos é seguro em comprovar a autoria delitiva, uma vez que o acusado foi detido no local após a observância da comercialização de drogas pelos guardas municipais, bem como a apreensão de droga no local e quantidade em dinheiro, aliados à confissão do réu na fase de inquérito policial. Diante do seguro conjunto probatório, merece procedência a pretensão punitiva. No que se refere à aplicação da pena, observo pelas certidões de fls. 24/27, que o réu possui antecedentes criminais e é reincidente, razão pela qual a reprimenda deve ser majorada na primeira fase e reconhecida a agravante genérica, não sendo cabível o privilégio, impondo-se o regime fechado e vedado o direito de recorrer em liberdade. Em relação aos valores apreendidos, requeiro seja decretada sua perda em favor da União.

Dada a palavra ao (à) Dr. (A) Defensor (A), por ele (ela) foi dito: MMA. Juíza: Não existe prova segura para fundamentar a condenação. Com efeito, interrogado, o réu CLEITON esclareceu que já era conhecido dos GCMs que realizaram a sua abordagem. Disse que quando da abordagem estava pesando 52 kilos, sendo que estava em situação degradante em virtude do uso de drogas. Estava com droga para seu uso, pois a droga que era do traficante já havia feito a entrega. Estava com cerca de 27 pedras de crack, todas para seu uso. Estava em poder de um cachimbo, que foi jogado fora pelos guardas. Transportava a droga em troca de 30 pedras de crack. No momento da abordagem estava sob o efeito de drogas, tanto que dormiu em seu interrogatório policial e a autoridade policial precisou oferecer café para que acordasse. Na delegacia de polícia, fez um acordo com a autoridade policial, tendo feito uma delação premiada, e está temeroso por sua integridade física. A versão do réu mostrou-se firme e coerente e não foi infirmada pela prova produzida. Ocorre que não há provas suficientes de autoria. Isso porque as testemunhas não relataram nenhuma situação de mercancia. Embora os guardas tenham confirmado a apreensão de drogas em poder do acusado, nenhuma testemunha civil foi arrolada, de modo a dar maior credibilidade ao relato dos guardas. O GCM Edson disse que foram dispersar os usuários da cracolândia, quando o réu colocou um saco dentro do boné e o boné na cabeça, o que motivou a sua abordagem. Ao realizarem a abordagem, constatou-se a existência de crack em poder do acusado. Havia aproximadamente 150 a 160 pedras de crack e cerca de R\$111,00 em dinheiro. Indagado, o réu admitiu a propriedade das drogas e disse que “a casa caiu” e foi então conduzido à delegacia. Não conhecia o réu anteriormente. Não visualizou nenhum ato de mercancia. Indagado a respeito da divergência de seu depoimento na polícia, em que não noticia ter visualizado o réu colocar uma sacola dentro do boné, disse que visualizou o réu colocando uma sacola

no boné e que abordou o acusado também em razão do nervosismo. Indagado, disse que não apreendeu cachimbo ou outros instrumentos em poder do acusado. Indagado, disse que o acusado possuía alguns rasgos na roupa, mas não aparentava ser usuário ou morador de rua, “era normal”. O GCM Diego disse que o réu estava pelo local dos fatos e sua equipe estava em apoio aos agentes que fazem a manutenção do local, cracolândia. O réu foi avistado colocando uma sacola dentro do boné. Em razão disso, foi feita a abordagem e encontrado em poder do acusado cerca de 141 porções de crack. O réu foi conduzido à delegacia e apresentado à autoridade de plantão. Foram localizadas moedas em poder do acusado. Indagado, o réu disse que fazia mercancia de drogas. Não conhecia o réu anteriormente. Indagado a respeito da divergência entre seu depoimento na polícia e em juízo, disse que na verdade o que chamou a atenção dos guardas foi o fato do réu colocar uma sacola sob o boné. Indagado, disse que não foi localizado cachimbo ou outros apetrechos com o acusado, próprios de usuários. Assim, diante de tamanhas inconsistências, não há como se conferir aos depoimentos das guardas qualquer valor probatório. Mas ainda que assim não fosse, é forçoso reconhecer que a atuação dos GCMs no presente caso revestiu-se de inconstitucionalidade. A GCM atuou fora de suas atribuições constitucionais no caso. Isso leva à exclusão da prova da autoria e da materialidade colhidas exclusivamente em razão de sua atuação, e à subsequente absolvição. Os guardas afirmaram que policiavam o local e, em razão disso, notaram a atitude suspeita do réu colocando uma sacola sob o boné e o abordaram. Na sequência, encontraram entorpecentes ilícitos em sua posse e o detiveram. Pois bem. Atuaram, no caso, como polícia preventiva. Afinal, agiram realizando busca pessoal para reprimir crimes em geral, sem qualquer relação direta com bens, instalações ou serviços municipais, sem competência constitucional para tanto. E não presenciaram qualquer infração penal, pois a atitude suspeita relatada não é crime. Diante do que dispõe o art. 144 da CF, a GCM não possui competência constitucional para realizar investigações ou atuar na repressão geral do delito ou atuar ostensivamente. Isso porque a segurança pública é exercida pelas polícias, em rol exaustivo tratado pelo caput do dispositivo. A GCM foi excluída dessa atribuição propositalmente pelo constituinte. A ela cabe exclusivamente a proteção de bens, serviços e instalações municipais, como prevê o parágrafo 8º. Desse modo, não lhe cabe investigar ou diligenciar para a solução ou repressão de delitos. Também não é devida a abordagem de pessoas que não estejam cometendo delito. Em outros termos, não lhe cabe a avaliação geral do que é “fundada suspeita” e a busca pessoal, nos termos do artigo 244 do CPP. Essas funções são reservadas às policiais, e a GCM não é uma polícia municipal. Assim caminham tanto o STJ como o STF. Como bem apontou o STJ em decisão paradigmática, “a Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras “polícias municipais”, mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte, apesar das investidas em contrário, por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal” (g.n.) (REsp n. 1.977.119/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022). Ou seja, não cabe à GCM realizar qualquer ato reservado à polícia. Aqui, tratamos especificamente da realização de diligências, tal como a busca pessoal disciplinada no artigo 244 do CPP. É claro que, como qualquer do povo, a GCM pode realizar a prisão em flagrante de alguém (art. 301 do CPP). Contudo, se o flagrante não for claro, evidente, notório e, desse modo, cobrar a realização de medidas invasivas ou diligências para a sua verificação, não é possível que qualquer pessoa e, assim, a GCM, possa empregá-las. Aqui, somente a polícia tem a atribuição para agir. A decisão acima destaca essa conclusão: “(....) A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por

consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito. (...)Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipotente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes” (g.n.). Portanto, não é atribuição da GCM proceder diligências policiais gerais. Nesse ponto, merece destaque, igualmente, a posição do STF concluída no RE n.º 1.281.774: Por outro lado, não comungo do entendimento no sentido de que tais instituições estejam autorizadas a realizar diligências investigativas ou diligências prévias voltadas à apuração de crimes, como na situação retratada nos autos. No caso, é notório que os guardas municipais agiram como polícia investigativa. Afinal, ao atender à denúncia anônima, localizaram o indivíduo, mas, ao não encontrarem drogas em posse do réu, decidiram investigar na residência do recorrido, a fim de dar continuidade à busca por substâncias ilícitas, o que extrapola, sobremaneira, as atribuições legais e constitucionais conferidas pelo ordenamento jurídico aos guardas municipais. (g.n.) (RE 1281774 AgR-ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 25-08-2022, PUBLIC 26-08-2022). Também decidiu desse modo o órgão especial do TJSP, que declarou inconstitucional lei do município de São Paulo que atribuía a função de polícia à GCM: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - art. 1º, inc. I da Lei n. 13.866/2004, do Município de São Paulo, que fixa atribuições da Guarda Civil Metropolitana - Art. 147 da Constituição Estadual - Proteção dos bens, serviços e instalações municipais - Matéria debatida é atinente à segurança pública - Preservação da ordem pública - Competência das polícias, no âmbito do Estado - Atividade que não pode ser exercida pelas guardas municipais - Extrapolação dos limites constitucionais - Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo”. (g.n.) (TJSP. Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 9034981-58.2007.8.26.0000; Relator (a): Maurício Ferreira Leite; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - São Paulo; Data do Julgamento: 10/12/2008; Data de Registro: 05/02/2009). Bem é verdade que o RESP supracitado, visando dar parâmetros à atuação da GCM, ressalva somente a busca pessoal ligada a suspeita de flagrante de crime diretamente relacionado a bens, instalações e serviços municipais. Entretanto, essa não é a hipótese dos autos. Em resumo, a GCM, no caso, realizou diligências próprias da polícia, extrapolando os limites autorizados para a prisão em flagrante por qualquer do povo, a ela aplicáveis. Por conseguinte, descobriu a materialidade e a autoria em desacordo com o sistema normativo pátrio. Isso leva à exclusão desses dados. Dispõe o art. 5º, LVI, da Constituição: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”. Ao discorrer sobre o tema, Ada Pellegrini Grinover expõe o conteúdo da ilicitude: “A inadmissibilidade processual da prova ilícita torna-se absoluta, sempre que a ilicitude consista na violação de uma norma constitucional, em prejuízo das partes ou de terceiros. Nesses casos, é irrelevante indagar se o ilícito foi cometido por agente público ou por particulares, porque, em ambos os casos, a prova terá sido obtida com infringência aos princípios constitucionais que garantem os direitos da personalidade”. (Liberdades Públicas e Processo Penal. 2ª ed. 1982, RT. p. 151). Nesse trilho, merece destaque a seguinte manifestação do STF: “A garantia constitucional da proibição da prova ilícita dá ao réu o direito de não ser denunciado, processado nem condenado com base em elementos probatórios obtidos ou produzidos em incompatibilidade com os limites éticos-jurídicos que circunscrevem a

atuação estatal no tocante à persecução penal." (STF. HC 90298, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 08/09/2009, DJe-195 DIVULG 15-10-2009 PUBLIC 16-10-2009 EMENT VOL-02378-02 PP-00353 RB v. 21, n. 553, 2009, p. 35-36). Logo, qualquer ato que viole preceitos constitucionais e legais constitui-se como prova ilícita. Esse entendimento foi consolidado em lei, conforme dispõe o art. 157, caput, do Código de Processo Penal: "São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais". A postura em comento violou as normas supracitadas, quais sejam, o artigo 144, §8º da CF e artigo 244 do CPP. Com isso, os elementos dela obtidos e os que dela derivaram - prova da autoria e da materialidade - estão igualmente contaminados e devem ser desentranhados dos autos, diante do que determina o art. 157 já citado, bem como seu §1º: "São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras". Realizado o desentranhamento, conclui-se que inexistente a prova da autoria e da materialidade, devendo, então, ser absolvido. É, a propósito, o desfecho determinado pelo STJ na decisão acima mencionada: "À vista do exposto, dou provimento ao recurso especial para, reconhecida a violação dos arts. 157 e 244 do CPP, declarar ilícitas as provas colhidas pelos guardas municipais em atividades alheias às suas atribuições, bem como todas as que delas decorreram e, por consequência, absolver o réu, com fundamento no art. 386, II, do CPP". Diante do exposto, o acusado deve ser absolvido, nos termos do art. 386, II e V, do CPP. Dessa maneira, observa-se que a prova acusatória resumiu-se aos depoimentos dos guardas. Todavia, tais testemunhos devem ser avaliados com cautela, tendo em vista que os agentes da lei são parciais, uma vez que têm todo o interesse em apresentar versões que atestem a eficiência dos trabalhos que desempenharam anteriormente. Posto isso, requer a defesa a ABSOLVIÇÃO do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Em caso de entendimento diverso, por apego aos princípios da oportunidade e da mais ampla defesa, requer-se, subsidiariamente: a) desclassificação para porte de drogas para uso próprio; b) atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e compensação com a agravante da reincidência; b) redução da pena em grau máximo (2/3) em razão do acordo de delação premiada firmado com a autoridade policial; d) regime diverso do fechado; e) direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).

A seguir, pela MMª Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Cleiton Weber Baloc, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque supostamente no dia 14 de julho de 2022, por volta das 17hs.45min., na Rua Mauá, bairro República, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 141 porções de "cocaína", na forma de "crack", com peso líquido de 26,2 gramas, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida (fls. 75/78), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 107), apresentou resposta escrita (fls. 110/111) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal (fls. 113) momento em que ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. Primeiramente, afastar a alegação da d. Defesa de ilegalidade da abordagem e prisão efetuada pelos guardas municipais. Nos termos do art. 144, § 8º, da Constituição Federal: "Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A Guarda Municipal tem por função precípua a proteção patrimonial dos bens municipais. Por outro lado, ainda que a Guarda Municipal não tenha poder de polícia, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito". Logo, sendo o guarda municipal um agente público, ao vislumbrar qualquer pessoa em flagrante delito, deverá prendê-la em estrita

obediência ao que prevê a norma processual. Além disso, o art. 3º da Lei Federal 13.022/14 autoriza o patrulhamento preventivo e o uso progressivo da força para cumprimento das funções de sua competência, in verbis: "Art. 3º São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: I - proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas; II - preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas; III - patrulhamento preventivo; IV - compromisso com a evolução social da comunidade; e V - uso progressivo da força.". Desta feita, não há que se apontar quaisquer ilegalidades na conduta dos guardas civis municipais. O réu estava na rua, na região da "cracolândia", local demasiadamente conhecido como ponto de tráfico, quando colocou um saco plástico no interior do boné que estava na cabeça e foi passar pelo "fluxo", demonstrando nervosismo. Tal conduta, somado ao local, deu guarida para que os guardas o abordassem, já que havia indícios de estado flagrancial. Portanto, perfeitamente legítima a abordagem in casu. Nesse sentido: "1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexistente ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC nº 667.413/SP, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/6/2021). E mais, "(...) Contudo, também é firme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice à sua realização por guardas municipais. Precedentes" (HC n. 357.725/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 12/05/2017). Precedentes. III - Destarte, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado v. aresto reprochado, bem como no auto de prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal. Ademais, no que tange ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o fundamento de que havia fundada suspeita para a referida diligência porquanto, em patrulhamento de rotina em local conhecido pelo tráfico de drogas (cracolândia), os guardas civis visualizaram o acusado em atitude suspeita, uma vez que tentou empreender fuga ao se deparar com a viatura, levando à abordagem que resultou na apreensão de entorpecentes de natureza extremamente deletéria. Precedentes" (STJ, HC 742.941/SP, 5ª Turma, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), DJe 16/08/2022). Ultrapassada tal questão, no mérito, a ação penal procedente. Assim porque ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório. A materialidade do delito está comprovada através do auto de constatação (fls. 17/19), laudo químico toxicológico (fls.103/105) e prova oral coligida. A autoria também é indubitável. Coram iudice o réu disse que estava apenas com 27/30 pedras de "crack" que ganhava para fazer entrega de drogas. Tinha acabado de fazer a entrega quando foi abordado. Atuava na função de "lagarto", ou seja, apenas transportava as drogas. Nega a venda de substâncias. Dias antes foi abordado pelo mesmo guarda municipal ouvido em audiência. No dia dos fatos estava com as drogas soltas no bolso, cigarro e cachimbo. Eles pisaram no cachimbo e o levaram para o D.P. No momento da abordagem estava sob efeito de drogas e o Delegado lhe ofereceu café para que acordasse. Demais disso, o guarda civil metropolitano Edson Marques da Costa narrou que no dia dos fatos estava na "cracolândia" e havia uma grande quantidade de pessoas que seriam dispersadas para a limpeza no local por servidores da Prefeitura, quando viu o réu colocando um saco plástico na cabeça. Foi realizada a abordagem e as drogas foram localizadas no saco preto. Tinham várias porções de "crack" - aproximadamente 150/160 porções - e cerca de R\$ 111,00 em dinheiro. Questionado, o réu confessou a acusação e que a droga era dele. Não conhecia o réu anteriormente. O réu olhou, colocou a droga dentro do boné

e foi passar pelo fluxo demonstrando nervosismo. Não se recorda de ter encontrado cachimbo em poder do réu. Nunca abordou o réu anteriormente. O réu não aparentava ser usuário ou morador de rua. No mesmo sentido o guarda civil metropolitano Diego do Espírito Santo afirmou que estava no Largo General Osório e sua equipe apoiava a equipe de manutenção da Prefeitura quando viram o réu colocando uma sacola no boné dele. Realizaram a abordagem e na sacola estavam 141 porções de "crack" e moedas. O réu confessou que praticava a traficância do produto localizado em seu poder. Tinham aproximadamente 30/40 pessoas no local. O nervosismo não foi essencial para a abordagem, mas sim o local e a atitude dele. Nunca abordou o réu anteriormente. Não foram localizados apetrechos para uso de entorpecente em poder do réu. Ressalto, outrossim, que os guardas sequer conheciam o denunciado quando da ocorrência, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente. Por fim, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do réu, aliadas ao local, não deixam dúvidas que o entorpecentes se destinavam inequivocamente à traficância, se subsumindo, desta forma ao artigo 33, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual inviável a desclassificação delitiva pretendida pela d. Defesa. Comprovadas, assim, autoria e materialidade delitivas, o decreto condenatório é medida que se impõe. Assim é que decido. Passo à dosar a pena. Atendendo ao art. 59, do Código Penal, c.c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base do acusado um sexto (1/6) acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes ostentados (fls. 25/26 - 4ª Vara Criminal - processo nº 0074604-93.2011 e processo nº 0078676-84.2015), fixando-a em 05 (cinco) anos e dez (10) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase de fixação de pena, observo que o réu ostenta reincidência criminal (fls. 26 - 1ª Vara Criminal de Presidente Prudente - processo nº 1500027-76.2018), contudo, confessou, ainda que parcialmente em juízo e informalmente aos guardas a prática do delito, razão pela qual compenso tais circunstâncias e mantenho a pena anteriormente fixada, que torno definitiva na ausência de outras circunstâncias modificativas. Assim porque inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, eis que o réu ostenta antecedentes e reincidência criminal (fls. 24/27), o que impede o reconhecimento do benefício. Ressalto, ainda, que inviável no presente momento a redução da pena em razão do acordo de delação premiada realizado, eis que este juízo de conhecimento não dispõe de elementos suficientes para verificar se atendidos os requisitos previstos no art. 4º, da Lei nº 12.850/2013. Por fim, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado em razão da pena ora fixada, antecedentes e reincidência criminal do réu, fatos que demonstram que apenas tal regime é o único compatível para a repressão e prevenção de sua conduta, nos termos do art. 33, do Código Penal. Pelo mesmo motivo, não poderá apelar em liberdade. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno Cleiton Weber Baloc, qualificado nos autos, à pena de em 05 (cinco) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incursão no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Vedado ao réu o apelo em liberdade, eis que ainda presentes os requisitos do art. 312, do C.P.P., mormente diante da presente sentença condenatória. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se à V.E.C. Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas. Oficie-se ao Distrito Policial. Ainda, decreto o perdimento do valor apreendido em favor do FUNAD. Oficie-se ao Banco do Brasil. Isento de custas."

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (o) foi dito que: MMª Juíza, Ciente da sentença, este (esta) Promotor (a) de Justiça não apela.

Dada a palavra ao (à) Dr (a). Defensor (a), foi dito: Ciente da sentença. Desejo apelar da decisão.

O réu tomou ciência da sentença e manifestou o desejo de recorrer da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: Recebo o recurso de apelação interposto pela D. Defesa. Processe-se-o. Diante da manifestação do Ministério Público em não recorrer certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se guia de recolhimento provisória. Oportunamente, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a observância das formalidades legais.

Servirá a presente como ofício de recomendação do sentenciado CLEITON WEBER BALOC, Brasileiro, Casado, Barbeiro, RG 61844421, pai SERGIO VANDERLEI BARCELOS BALOC, mãe ENI SALETE WEBER, Nascido/Nascida 01/06/1993, de cor Pardo. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Pinheiros II - Av Nações Unidas, 1501, Vila Leopoldina - CEP 53100-00, São Paulo - SP, 11 3645 0113. Endereço: Rua Paulo Bourroul, 1429, Real Parque, RUA PAULO BOURROL, CEP 05686-050, São Paulo - SP, perante o estabelecimento prisional em que se encontrarem recolhidos.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.